

1500940-53.2021.8.26.0001

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Suzana Jorge de Mattia Ihara

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... não é admissível que a ré, já condenada por tráfico de entorpecente, desconhecesse a sua origem (fls. 87 a 88), fato que foi prontamente identificado pelas agentes penitenciárias. Terceiro, o procedimento administrativo é diverso do âmbito criminal e não cabe aqui a discussão do ingresso da droga da Penitenciária, até porque a acusação se restringe à posse da droga.

Assim, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

1ª VARA CRIMINAL REGIONAL I SANTANA

Av. Engenheiro Caetano Álvares nº 594 - 3º andar - sala 307, São Paulo - SP - cep 02546-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500940-53.2021.8.26.0001

Réu:

JOZEMEIRE DOS SANTOS SILVA

Vistos.

JOZEMEIRE DOS SANTOS SILVA foi denunciado e processado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 19 de agosto de 2020, por volta das 18h30, na Avenida General Ataliba Leonel, altura do número 656, São Paulo, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para uso próprio, cinco porções de substância entorpecente conhecida como LSD, que causa dependência física e psíquica.

Sem relatório (art. 81, 3º, da Lei nº 9.099/95).

Decido.

Em que pese a argumentação da combativa Defesa, o exame das provas revela que a ação penal é procedente, como demonstrou o Ministério Público.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, a testemunha Andressa Soares Lera informou que a droga foi encontrada em uma cesta, na cela da ré; naquela oportunidade, a ré admitiu a posse da droga (TEAMS).

Não foi produzida prova sem sentido contrário. A ré admitiu a posse do material, mas argumentou que não sabia se tratar de substância entorpecente (TEAMS).

À evidência, a versão da ré não prevalece.

Primeiro, não é crível que cinco porções de substância entorpecente estavam abandonadas no local de trabalho da acusada, uma penitenciária. Segundo, não é admissível que a ré, já condenada por tráfico de entorpecente, desconhecesse a sua origem (fls. 87 a 88), fato que foi prontamente identificado pelas agentes penitenciárias. Terceiro, o procedimento administrativo é diverso do âmbito criminal e não cabe aqui a discussão do ingresso da droga da Penitenciária, até porque a acusação se restringe à posse da droga.

Assim, a autoria é incontestável.

De outra parte, a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que apresenta resultado positivo e contém a necessária fundamentação (fls. 60). Não foram apresentados argumentos, de ordem objetiva, para afastar aquela conclusão.

Registre-se que o crime do art. 28 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, configura-se com a simples ocorrência dos fatos nele descritos, ou seja, "para a tipificação do delito basta que o agente tenha sido surpreendido, tendo consigo substância entorpecente, ainda que em quantidade ínfima, pois, cuidando-se de crime de perigo, sua configuração está vinculada à propriedade da droga, ao risco social e à saúde pública, e não à comprovação de lesividade da conduta ou à quantidade apreendida" (TJSP, Ap. 263.353-3/0, 1ª Câmara, j. 21-12-1998, rel. Des. Raul Motta, RT 765/584).

A pequena quantidade de substância entorpecente não descaracteriza o referido crime, que visa preservar a saúde pública. Nesse sentido: "A circunstância de ser mínima a quantidade da maconha encontrada em poder dos réus não prejudica a configuração da tipicidade do crime de porte, que está vinculada às propriedades da droga, ao risco social e de saúde pública, e não à lesividade comprovada em cada caso concreto" (STF, RE 109.619-5-SP, 1ª T., j. 19-8-1986, rel. Min. Octávio Gallotti, DJU de 19-9-1986, RT 614/402).

Em suma: A conduta da acusada tipifica o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 e não se verifica qualquer excludente da antijuridicidade.

Por fim, apesar de ter sido considerada matéria de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, não houve determinação para suspensão do julgamento desses casos, como consequência automática, interferindo apenas nos recursos extraordinários.

"DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO. TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Suspensão do processo. O reconhecimento de repercussão geral sobre matéria de apelação criminal não implica em automática suspensão do julgamento desta, limitando-se a interferir na admissibilidade de eventual recurso extraordinário. 2. E face do que dispõe o art. 28 da Lei nº 11.346/06 é típica a conduta de portar substância entorpecentes para uso pessoal. O fato de a Lei ter criado novas espécies de penas não contempladas no Código Penal não importa em revogação do preceito primário. 3. Insignificância. A pequena quantidade não é justificativa para descaracterizar o crime pela insignificância, pois tal dado já serve para caracterizar o consumo próprio (art. 28, §2º). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada e denúncia recebida" (2ª Turma Recursal dos Juizados Especial do Distrito Federal – Apelação Criminal no Juizado Especial APJ 20150410025499 - Relator: Aiston Henrique de Sousa – j. 23 de fevereiro de 2016).

Resta a aplicação da medida.

A Lei 11.343/06 trouxe inovações no tratamento penal ao crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28). A principal delas foi a abolição da pena privativa de liberdade. Com efeito, a referida infração penal somente pode ser

punida, após a vigência da referida Lei, com advertência sobre os efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato, a prisão da ré e a confissão, aplico-lhe a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no art. 28, inc. I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida contra JOZEMEIRE DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos. CONDENO-A à medida de advertência, por infração ao artigo 28, inc. I, da Lei 11.343/06.

Lance-se o seu nome, oportunamente, no rol dos culpados.

Audiência de advertência após o trânsito em julgado.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

SUZANA JORGE DE MATTIA IHARA
JUÍZA DE DIREITO